

1500789-95.2021.8.26.0063

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCELA MACHADO MARTINIANO

Comarca: Barra Bonita

Foro: Foro de Barra Bonita

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 11/02/2022

... para majorar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado sob pena de bis in idem. Acusado primário e portador de bons antecedentes. Inexistência de informações de que se dedique a atividades ilícitas ou que integre organização criminosa. Presença dos requisitos do tráfico privilegiado. Afastamento da hediondez do tráfico privilegiado. Desnecessidade de imposição de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barra Bonita

Foro de Barra Bonita

2ª Vara

Praça Dr. Meira, s/nº, Barra Bonita - SP - cep 17340-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500789-95.2021.8.26.0063 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500789-95.2021.8.26.0063

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado, Averiguado e Réu:

GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELA MACHADO MARTINIANO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia (fls. 152/155) em face de GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS e JOÁS MELKHIAS CARVALHO DA SILVA, já qualificados nos autos, imputando-lhes a prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos c.c. art. 40, III e VI, todos da Lei n.º 11.343/06 (LD), porque, supostamente, em data incerta, todavia anterior ao dia 18 de agosto de 2021, nesta cidade e Comarca de Barra Bonita/SP; associaram-se entre si e com o adolescente Marcelo Augusto do Nascimento para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas.

Consta da denúncia que no dia 18 de agosto de 2021, por volta de 17h00min, na Rua Emílio Veghin, nesta cidade e Comarca de Barra Bonita/SP, os réus, previamente ajustados e agindo em concurso com o adolescente, venderam 01 (uma) porção de crack, com peso líquido de 0,17 grama, bem como tinham em depósito, para fins de tráfico, 01 (uma) porção de maconha, com peso líquido de 5,14 gramas, e mais 05 (cinco) porções de crack, com peso líquido de 0,82 grama, tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Conforme a exordial, investigações realizadas pela Polícia Civil de Barra Bonita apontaram que os acusados e o adolescente estavam realizando de forma reiterada e contínua o tráfico de drogas na esquina das ruas Emílio Veghin e Armando Moretti, a cerca de 170 metros da Escola do Serviço Social da Indústria (SESI). Com lastro nessas informações, foi solicitado mandado de busca e apreensão para as residências de Gabriel e do adolescente, o que foi deferido (autos nº 1500771-74.2021.8.26.0063). Narra a exordial acusatória que, na data citada, por volta de 17hs, foi dado cumprimento ao mandado expedido; que os policiais visualizaram os acusados e o adolescente todos juntos, tendo presenciado o momento em que o usuário Luís Paulo Ferreira adquiriu uma porção de crack de Gabriel Ribeiro dos Santos e de Joás Melkhias. O usuário Luís Paulo Ferreira foi abordado logo em seguida e com ele foi apreendida a referida porção, a qual ele confirmou ter adquirido dos acusados; que, diligenciando na residência de Marcelo, encontraram 5 (cinco) pedras de crack no buraco de um muro, um telefone celular e a quantia em dinheiro de R\$ 10,00; que, na residência de Gabriel Ribeiro dos Santos, localizaram uma porção de maconha, bem como a quantia de R\$ 56,00, dinheiro que estava escondido dentro de suas roupas íntimas, além de seu telefone celular.

Cópia do mandado de busca e apreensão deferido - autos nº 1500771-74.2021.8.26.0063 - acostado às fls. 25/26.

Auto de prisão em flagrante às fls. 01/05.

Homologada a prisão em flagrante do réu Gabriel, foi convertida em preventiva (fls. 85/87).

A d. defesa impetrou habeas corpus (fls. 136/147), em favor de Gabriel, que teve sua liminar indeferida nos autos de n.º 2212502-21.2021.8.26.000.

Houve pedido pelo Ministério Público da prisão preventiva do réu Joás (fl. 152), oportunidade em que foi decretada a prisão (fls. 164/165). Mandado de prisão cumprido em 24/09/2021 (fls. 170/173).

Devidamente notificados (fls. 179 e 181), os acusados apresentaram defesa prévia (fls. 195 e 199/200).

Recebida a denúncia em 03/12/2021, foi designada audiência de instrução e julgamento, na modalidade virtual (fls. 201/202).

O habeas corpus impetrado pela defesa do réu Gabriel foi deferido às fls. 204/218. Alvará de soltura cumprido em 21/12/2021.

Em decisão de fls. 243/244, foi concedida liberdade provisória ao réu Joás, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Alvará de soltura cumprido em 19/01/2022 (fls. 253/255).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas testemunhas e, ao final, foram interrogados os réus.

Em alegações finais orais, a d. representante do Ministério Público requer a procedência da pretensão acusatória. Argumenta que a associação está comprovada em relação dos depoimentos dos policiais, que disseram que receberam denúncias referentes aos denunciados, tanto que realizaram campanhas prévias que ensejaram o deferimento de buscas. Alega que na data dos fatos, os policiais realizaram nova campanha, onde observaram a presença dos denunciados e do adolescente e efetuaram o cumprimento do mandado. Destaca o encontro de drogas nas casas de Gabriel e do adolescente; que foi possível filmar o usuário adquirindo uma porção de crack; que Gabriel entrega a droga enquanto Joás recebe o dinheiro. Argumenta que não se exige ajuste prévio, divisão de tarefas ou hierarquia, mas que foi descrita policial a divisão. Alega que o tráfico pontualmente realizado não foi isolado, mas sim no contexto de uma associação prévia, tanto que os policiais receberam as denúncias anônimas. Com relação ao delito do tráfico de drogas, aduz que os depoimentos dos policiais foram claros no sentido de que visualizaram a venda do entorpecente, além do encontro de droga nas buscas. Alega que a pequena quantidade não deve ser considerada isoladamente, pois é prática comum dos traficantes. Requer o reconhecimento das causas de aumento descritas na denúncia, pois foi encontrada droga na casa do adolescente e houve descrição da proximidade do local em relação a uma escola, ressaltando o caráter objetivo da majorante.

A d. defesa do réu Gabriel, por sua vez, pugna pela improcedência da pretensão acusatória. Alega que não há provas da estabilidade e permanência da associação

criminosa e que não é suficiente a mera reunião ocasional entre os agentes. Argumenta que o adolescente relatou que cada um por si exerceria sua própria atividade, independente dos demais. Quanto ao tráfico de drogas, pede a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas. Se não, pede a aplicação da causa de diminuição do §4º, considerando que estão presentes os requisitos, que são objetivos. Defende que o termo imediações deve significar acesso rápido e imediato, a ponto de que o agente possa se beneficiar do fluxo de pessoas que transitam pelo local. Pontua que a distância é de 180 metros, não configurando a causa de aumento. Quanto ao envolvimento do adolescente, alega que não há prova, devendo deixar de ser aplicada. Em caso de condenação, requer a consideração da atenuante da menoridade relativa, fixação de regime favorável e a substituição da pena por restritivas de direito.

A d. defesa do réu Joás argumenta que o réu negou a prática do tráfico e que o dinheiro foi pago por bebida alcoólica que adquiriu mais cedo. Alega que nos autos há imagem que prova a ingestão de bebida alcoólica. Pede a absolvição do acusado, já que não foi comprovado que participava dos crimes. Aduz que nada foi encontrado com ele em nenhum momento, que ele não foi abordado junto com os demais acusados e que os depoimentos dos réus são coerentes entre si. Destaca que o usuário disse que foi compelido a assumir que teria comprado a droga dos acusados. Ressalta que não pode haver inversão do ônus acusatório. Argumenta que nem sequer pode haver imputação do delito de uso de drogas, pois nada foi encontrado com ele. Quanto à associação, assinala que policial Kevin não tinha conhecimento do envolvimento de Joás e que esse não estava presente. Ressalta que não havia envolvimento do adolescente, que agiu por si só, e que no celular do menor nada foi encontrado. Alega que deve haver liame subjetivo, que claramente não teria acontecido, já que Joás nem era conhecido dos meios policiais. Assim, requer absolvição do acusado em relação a ambos delitos. Em caso de condenação, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, pela fixação da pena base no mínimo legal, pela consideração de menoridade relativa e regime inicial aberto, além de pleitear a substituição da pena por restritivas de direitos.

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, e ausente, ainda, qualquer nulidade processual, passo ao exame do mérito.

1. Do art. 33 da Lei nº 11.343/2006

A materialidade dos fatos resta comprovada pelos seguintes documentos acostados aos autos: auto de prisão em flagrante (fls. 01/05); termos de depoimento (fls. 06/10); termos de declarações (fls. 12, 14 e 96); termo de interrogatório (fl. 15); boletim de ocorrência n.º 811/2021 (fls. 19/24); relatório nº 364/2021 (fls. 27/33); auto de exibição/apreensão (fls. 34/35); auto de constatação preliminar (fls. 36/37); fotografias (fls. 63/66); relatório de investigação nº 371/2021 (fls. 102/104); laudo pericial definitivo (fls. 105/112); relatório final do inquérito policial (fls. 113/124); bem como pela prova oral colhida.

Sobreleva notar que as substâncias apreendidas (tetrahydrocannabinol e cocaína, essa na forma de crack) se encontram expressamente previstas na Portaria n.º 344/98 e Resolução n.º 104 da Anvisa, amoldando-se perfeitamente à definição legal de droga (art. 1º, §1º, da LD).

Da mesma forma, a prova se revela idônea para ilustrar a autoria, porque o conjunto probatório amealhado em sede judicial está em consonância com os elementos já obtidos na fase inquisitorial.

A testemunha Kevin Akio Ikegami, policial civil, declarou que já tinham feito investigações anteriores; que fizeram campana e há vídeo de usuário comprando drogas no local; que tinham um mandado de busca na casa de Gabriel; que fizeram a campana e flagraram o usuário comprando; que abordaram o usuário, que confirmou que comprou na esquina; que então efetuaram os mandados de busca; que foi encontrada 1 porção de maconha na casa de Gabriel. Lembra-se que estavam Melkhias, Gabriel Ribeiro e o adolescente na esquina. Afirma que Gabriel entregou droga para o usuário. Informa que ficaram de 30 a 40 minutos fazendo campana e que em dias anteriores fizeram campana e visualizaram movimentação típica de tráfico de drogas.

Relata que conseguiram filmar apenas um usuário. Não se recorda do que Gabriel falou no momento da busca em sua casa. Disse que, salvo engano, o usuário estava com crack. Afirma que na primeira campana estavam em um local ruim e viram o Gabriel e Joás Melkhias. Depois, perceberam que eles desconfiaram, viram a movimentação, mas não flagraram compra e venda de drogas naquele dia. Diz que ali perto tem uma escola do Sesi, a 150 metros mais ou menos. Informa que conhecia Gabriel, mas não o Joás. Afirma que perceberam que Joás era responsável por receber o dinheiro; que Marcelo provavelmente estava na função de olheiro; que Gabriel entregava droga. Repete que na primeira campana estavam em uma localização ruim e que já houve informações no siga de que havia tráfico ali. Disse que Sesi está a 1 quarteirão e meio mais ou menos do local. Esclarece que o menor é amigo de Gabriel e que estava vendendo crack. Disse que logo que o usuário desceu à rua, o pessoal da esquina viu a viatura e então dispersaram. Por isso, cumpriram o mandado de busca na casa de Marcelo e na casa de Gabriel.

No mesmo sentido, a testemunha Ricardo Gonçalves Nunes, também policial civil, contou que houve denúncias de tráfico na localidade; que começaram a fazer campanas para identificar os possíveis traficantes; que encontraram Joás Melkhias, o menor e Gabriel Ribeiro; que registraram a venda para um usuário; que encontraram 1 pedra de crack com o usuário, que afirmou que comprou deles; que nesse momento eles saíram da esquina e não conseguiu nada que comprovasse o envolvimento no crack; que tinham ordem de busca na residência de Gabriel e do adolescente; que encontraram porção de maconha na casa de Gabriel Ribeiro e algumas pedras de crack na casa do adolescente. Disse que fizeram uma breve campana ali no local, em torno de meia hora, até conseguirem a filmagem. Relatou que estavam Joás, Marcelo e Gabriel não estava em um primeiro momento; que depois Joás saiu e Gabriel chegou; que Joás recebeu o dinheiro e Gabriel foi buscar o entorpecente na residência e entregou para o usuário. Disse que eles foram vistos no local durante as campanas. Não se recorda de ter visto divisão de tarefas em outra campana, mas estavam todos no local. Esclarece que dá a impressão de que é pouco entorpecente, mas eles deixam pouca droga no local para não caracterizar o tráfico. Afirma que, quando abordaram o usuário, eles saíram da esquina; que eles podem ter se desfeito das drogas. Relatou que as casas são humildes e precárias e que não foi identificado nenhum veículo de uso deles.

A testemunha Luis Paulo Ferreira relatou que no dia, saiu de lá e veio pra cá; que compraram uma bebida na manhã; que entregou 10 reais para Mel; que não viram droga com ele; que já estava bebendo e usando droga; que entregou 10 reais para Mel para pagar a bebida que compraram mais cedo; que Mel tinha emprestado dinheiro; que já o conhecia porque ele mora na região da casa dele; que usa crack; que Gabriel é vizinho no bairro; que o adolescente também mora no bairro; que nunca viu os acusados vendendo droga; que não disse em Delegacia que comprou droga do Gabriel; que ficaram o oprimindo para falar isso.

A testemunha Aparecida F. Castro Marceliano disse que não sabe nada sobre os fatos. Afirmou que sabe que Gabriel estava trabalhando com o pai.

A testemunha Karina Ap. do Nascimento contou que nada sabe sobre os fatos. Disse que os conhece porque moram na mesma rua que ela. Afirmou que ele estava trabalhando um tempo atrás.

O réu Gabriel Ribeiro dos Santos, interrogado, declarou que estavam na esquina e chegou o usuário; que ele foi para a casa dele; que a polícia então invadiu sua casa; que estava na esquina bebendo; que estava ele, Joás e o Gabriel Oscar; que é usuário de maconha; que mora com sua mãe e com seu pai; que seus pais te dão dinheiro e então compra droga; que o usuário veio pagar 10 reais para Mel por dívida de loló; que havia umas 5 gramas de sua casa, que comprou por uns 20 reais; que consome essa droga em 2 dias.

Em seu interrogatório, Joás Melkhias Carvalho da Silva alegou que estava apenas esperando Luis porque ele iria pagar bebida que comprou mais cedo; que já conhecia o Gabriel antes, há pouco tempo; que estavam ele, o Gabriel e Marcelo no local; que é usuário de maconha; que mora com os pais.

No entanto, as narrativas dos réus, não encontram amparo nas demais provas produzidas. Os depoimentos das testemunhas, coerentes e harmônicos entre si, deixam

isoladas as versões dos réus, que, por isso, não são suficientes para incutir dúvida razoável.

Não há motivos para não dar créditos à palavra dos policiais que atuaram no caso, conforme a jurisprudência do C. STJ (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) e do E. TJSP (TJSP; Apelação Criminal 0014180-58.2012.8.26.0565; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Caetano do Sul - 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 14/05/2019; Data de Registro: 15/05/2019). Não constam rixas envolvendo os réus e as testemunhas, que, inclusive, foram devidamente compromissadas em juízo, nos termos do art. 203 do CPP.

Ademais, os policiais foram enfáticos ao afirmarem, em juízo, que visualizaram o usuário Luis Paulo comprando a porção de droga com os acusados. Além disso, houve a apreensão das drogas na residência de Gabriel e do adolescente, tudo corroborando a prática do tráfico. Também cumpre pontuar que em sede policial, houve confirmação da testemunha Luis Paulo, um dos abordados, de que adquiriu a droga naquele lugar (fl. 12).

Outrossim, o local onde os acusados foram presos em flagrante - ponto de drogas conhecido da comarca -, as circunstâncias do flagrante - que envolveram campana e filmagem da compra e venda, com individualização das condutas-, bem como os depoimentos colhidos em juízo indicam que os entorpecentes não se destinavam ao consumo pessoal, e sim à mercancia, a despeito da pequena quantidade encontrada (art. 28, § 2º, da LD).

Dessa forma, tenho que as condutas praticadas pelos acusados amoldam-se ao delito de tráfico de drogas, uma vez que praticaram o núcleo "vender" e "ter em depósito" e, em se caracterizando a figura do art. 33 da LD como tipo misto alternativo, a prática de qualquer de seus verbos é apta a configurá-lo.

Ausentes agravantes. Incidente a atenuante da menoridade relativa em relação aos réus, pois eram menores de 21 anos na data dos fatos (art. 65, I, da LD).

Concorre a minorante do art. 33, §4º, da LD, uma vez que os réus são primários, com bons antecedentes (fls. 68/69 e 242), incidindo em seus favores a presunção de que eles não se dedicam a atividades criminosas, uma vez que não há elementos nos autos que a infirmem, cabendo ressaltar que nenhum dos acusados possuem registros de atos infracionais. Ademais, não se pode concluir que estavam em associação para o tráfico, conforme será abordado no próximo tópico.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. STF:

(...) A previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. Conforme assentado na doutrina: "A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena". (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas . 2016. p. 50). E também: "(...) militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, nesse caso, é do Ministério Público (...)". (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de Drogas anotada . 2009. p. 109). Tecidas as considerações pertinentes e preenchidas as condições do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, tem a paciente o direito à redução, uma vez que se cuida de ré primária, tem bons antecedentes e não há qualquer indicação de envolvimento em efetiva organização criminosa. HC 154694 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020).

A fração de diminuição será a de 2/3, por inexistirem circunstâncias que justifiquem a redução em menor patamar.

Destarte, promovo a emendatio libelli, com fulcro no art. 383 do CPP, para que a capitulação do delito conste como a do art. 33, caput e §4º, da LD. Por outro lado, concorrem as majorantes do art. 40, III e VI, da LD em relação a ambos os acusados. Restou cabalmente comprovado que a prática do tráfico envolveu o adolescente M.A.N.. O relatório de investigação de fls. 27/33 indica que o adolescente e os acusados foram vistos pelos policiais civis praticando a mercancia. Tal circunstância foi confirmada pela busca e apreensão, ocasião em que foram localizados os entorpecentes na residência do adolescente. Ademais, a mercancia era realizada a aproximadamente 180 metros do estabelecimento de ensino (Escola SESI), conforme imagem juntada aos autos à fl. 27, o que foi confirmado em juízo pelos testemunhos dos policiais. Nesse sentido:

Apelação. Tráfico de drogas. Recursos do Ministério Público e da Defesa. 1. Recurso ministerial. Pleito objetivando a majoração da pena-base, o afastamento do tráfico privilegiado, o regime inicial fechado e inaplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Descabimento. Quantidade não elevada de drogas. Impossibilidade da utilização da quantidade e natureza dos entorpecentes para majorar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado sob pena de bis in idem. Acusado primário e portador de bons antecedentes. Inexistência de informações de que se dedique a atividades ilícitas ou que integre organização criminosa. Presença dos requisitos do tráfico privilegiado. Afastamento da hediondez do tráfico privilegiado. Desnecessidade de imposição de regime mais severo. 2. Recurso defensivo. Pleito objetivando o afastamento da causa de aumento dada pelo art. 40, III, da Lei de Drogas e a fixação do regime aberto. Causa de aumento demonstrada. Presença de estabelecimento de ensino nas imediações do local onde o tráfico era realizado. Comprovação pela prova oral e pela juntada de mapa. Desnecessidade de realização de perícia. Causa de aumento de índole objetiva. Desnecessidade de comprovação de que algum estudante tenha sido atingido pela conduta ilícita praticada pelo réu. Precedentes do STJ. Cabimento do regime aberto. Acusado primário e pena fixada abaixo de 4 anos de reclusão. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Recurso ministerial não provido. Recurso defensivo parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1502519-54.2019.8.26.0535; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 6ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020) (grifei).

Nessa toada, a pena do delito de tráfico será aumentada em 1/5, em razão da incidência das majorantes do art. 40, III e VI, da LD.

2. Do art. 35 da Lei nº 11.343/2006

Quanto ao crime previsto no art. 35 da LD, não vislumbro a existência de materialidade dos fatos. Não restou demonstrado pela prova produzida que haveria associação estável e duradoura, com vinculação sólida, constituída para o fim de praticar uma série indeterminada de crimes.

O topo do art. 35 desta lei dispõe: "associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei". O tipo objetivo do art. 35 pune a associação para o tráfico, ao passo que o tipo subjetivo consiste no dolo específico de se associar, de forma permanente ou estável, para praticar tais crimes. O objeto material e jurídico é a paz pública.

Para a configuração de tal delito, não basta que o acusado esteja ligado a "atividades criminosas" (expressão usada pelo art. 33, §4º), sendo necessário demonstrar de forma sólida que havia uma associação organizada de forma estável e permanente para a prática do crime de tráfico. Ressalta-se que a estabilidade e a permanência do vínculo entre os associados são requisitos imprescindíveis para configuração do tipo penal. Nesse sentido:

CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Sentença absolutória - Quadro probatório frágil – Insuficiência de provas no tocante à associação – Crime autônomo que demanda prova do elo perene e estruturado entre os agentes para a prática da traficância – Absolvição mantida – CRIME DE TRÁFICO – Invasão de domicílio –

Ilícitude das provas - Inocorrência - Crime permanente - Preliminar afastada - Quadro probatório seguro e coeso a evidenciar autoria e materialidade do delito - Depoimentos de policiais militares - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Inexistência de dúvida que justifica o decreto condenatório - Pena correta - Réu reincidente - Ré primária - Redutor concedido à ré - Regimes corretos - Recursos improvidos" (TJSP; Apelação Criminal 0001360-41.2017.8.26.0594; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/04/2019; Data de Registro: 22/04/2019, g.N.).

HABEAS CORPUS. ART. 35, DA LEI N. 11.343/2006. NECESSIDADE DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO PARA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MERO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 2. O acórdão impugnado, ao concluir pela condenação do paciente e do corréu pelo crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, em momento algum fez referência ao vínculo associativo estável e permanente porventura existente entre eles, de maneira que, constatada a mera associação eventual entre os acusados para a prática do tráfico de drogas - sem necessidade de reavaliação probatória ou exame de fatos -, devem ser absolvidos do delito em questão. 3. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, para absolver o paciente do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, com extensão dos efeitos desse decisor para o corréu, a teor do art. 580 do CPP." (STJ - HC: 270837 SP 2013/0159054-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/03/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2015) .

Explica ainda o des. Guilherme de Souza Nucci, em relação ao crime do art. 35 da Lei nº 11.343/06, que: "é a quadrilha ou bando específica do tráfico ilícito de entorpecente. Em nosso entendimento, cuida-se de delito equiparado a hediondo, como os arts. 33 e 34 (antigos arts. 12 e 13 da Lei 6.368/76), pois a associação criminosa tem justamente essa finalidade, vale dizer, o tráfico. Demanda-se a prova de estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa. (...) Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável". (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 10. ed. vol. 2. Rio de Janeiro: Forense, 2017).

No caso dos autos, embora seja certo o concurso de pessoas, bem como esteja bem caracterizado nos autos o propósito de destinação dos entorpecentes ao consumo de terceiros, não há prova suficiente da estabilidade e permanência para configuração do crime de associação para o tráfico.

Destaco que, embora realizada investigação prévia, é certo que, além da campana que ocorreu no dia dos fatos em análise, os policiais relataram em juízo que realizaram apenas uma outra campana anterior, durante a qual, embora tenham visto movimentação no local, não puderam identificar qualquer ato de compra e venda de entorpecentes. De outras campanas realizadas não se tem prova nos autos e não se pode olvidar que, do ponto de vista da técnica jurídica compatível com o rigor do processo penal, as provas sob contraditório deram conta de concurso de pessoas apenas na data dos fatos.

Desta forma, o Ministério Público não se desincumbiu no tocante à imputação pela associação para o tráfico, principalmente por não demonstrar o vínculo ilícito estável e permanente entre os agentes, tratando-se de mero concurso de pessoas. Assim, a absolvição dos acusados pela imputação da associação, com base no art. 386, VII, do CPP, é medida que se impõe.

Verifico que, na data dos fatos, os acusados eram imputáveis, tinham potencial consciência da ilicitude de seus comportamentos e lhes eram exigíveis condutas diversas. A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que os acusados efetivamente praticaram os fatos descritos na denúncia, razão pela qual devem responder criminalmente pelo ocorrido.

Em observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), o qual se respalda no critério trifásico proposto por Nelson Hungria e adotado no art. 68 do CP, passo à dosimetria das penas.

Da dosimetria da pena do réu Gabriel Ribeiro dos Santos

Na primeira fase (arts. 59 do CP e 42 da Lei n.º 11.343/2006), identifico que a culpabilidade é intrínseca ao tipo penal. O réu não possui maus antecedentes (fls. 68/71). Não há elementos concretos acerca de sua conduta social e personalidade. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime é comum à espécie. Não há que se falar em comportamento da vítima, pois o crime é vago. A quantidade e a natureza de droga devem ser sopesadas em conjunto, e a despeito da variedade dos entorpecentes, as quantidades são diminutas, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), todavia, deixo de reduzir a pena, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, concorre a minorante do art. 33, § 4º, da LD, razão pela qual diminuo a pena em 2/3, resultando em pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias- multa.

Ademais, presentes as majorantes prevista no art. 40, III e VI, da Lei n.º 11.343/2006, em razão do local do tráfico de drogas e do envolvimento de adolescente, aumento a pena em 1/5, resultando em 2 anos de reclusão e 199 dias-multa.

Assim, deve Gabriel Ribeiro dos Santos ser definitivamente condenado a 2 anos de reclusão e 199 dias-multa.

De acordo com a atual redação do § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, "o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Da leitura do aludido dispositivo legal, infere-se que a detração, na sentença condenatória, será necessária quando, descontado da pena definitiva fixada o tempo em que o réu ficou preso ou internado provisoriamente, houver mudança no regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, com o nítido escopo de evitar a continuidade da imposição de indevido regime mais gravoso, facilitando aos sentenciados a primeira progressão de regime. Entretanto, no caso dos autos, embora o réu tenha permanecido, por algum tempo, preso processualmente, vislumbro que a detração em nada alterará o regime fixado, de maneira a mostrar-se mais adequado que ela seja procedida no Juízo da Execução para cômputo de pena cumprida. Por conseguinte, deixo de proceder à detração.

O regime inicial será o aberto, com fundamento no art. 33, § 2º, c, do CP, diante das circunstâncias judiciais favoráveis preponderantes.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do acusado, fixo o valor do diamulta em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (arts. 49, §§ 1º e 2º, e 60, caput, do CP e art. 43 da Lei n.º 11.343/2006).

Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44, § 2º, do CP), quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana (arts. 43, IV e VI, do CP), a serem especificadas pelo juízo da execução.

Substituída a pena e também em razão do seu quantum, incabível o sursis penal (art. 77, caput e § 3º, do CP).

Da dosimetria da pena do réu Joás Melkhias Carvalho da Silva

Na primeira fase (arts. 59 do CP e 42 da Lei n.º 11.343/2006), identifico que a culpabilidade é intrínseca ao tipo penal. O réu não possui maus antecedentes (fl. 242). Não há elementos concretos acerca de sua conduta social e personalidade. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime é comum à espécie. Não há que se falar em comportamento da vítima, pois o crime é vago. A quantidade e a natureza de droga devem ser sopesadas em conjunto, e a despeito da variedade dos entorpecentes, as quantidades são diminutas, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante da menoridade relativa (art. 65,

I, do CP), todavia, deixo de reduzir a pena, em observância à Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, concorre a minorante do art. 33, § 4º, da LD, razão pela qual diminuo a pena em 2/3, resultando em pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias- multa.

Ademais, presentes as majorantes prevista no art. 40, III e VI, da Lei n.º 11.343/2006, em razão do local do tráfico de drogas e do envolvimento de adolescente, aumento a pena em 1/5, resultando em 2 anos de reclusão e 199 dias- multa.

Assim, deve Joas Melkhias Carvalho da Silva ser definitivamente condenado a 2 anos de reclusão e 199 dias-multa.

De acordo com a atual redação do § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, "o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Da leitura do aludido dispositivo legal, infere-se que a detração, na sentença condenatória, será necessária quando, descontado da pena definitiva fixada o tempo em que o réu ficou preso ou internado provisoriamente, houver mudança no regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, com o nítido escopo de evitar a continuidade da imposição de indevido regime mais gravoso, facilitando aos sentenciados a primeira progressão de regime. Entretanto, no caso dos autos, embora o réu tenha permanecido, por algum tempo, preso processualmente, vislumbro que a detração em nada alterará o regime fixado, de maneira a mostrar-se mais adequado que ela seja procedida no Juízo da Execução para cômputo de pena cumprida. Por conseguinte, deixo de proceder à detração.

O regime inicial será o aberto, com fundamento no art. 33, § 2º, c, do CP, diante das circunstâncias judiciais favoráveis preponderantes.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do acusado, fixo o valor do diamulta em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (arts. 49, §§ 1º e 2º, e 60, caput, do CP e art. 43 da Lei n.º 11.343/2006).

Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44, § 2º, do CP), quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana (arts. 43, IV e VI, do CP), a serem especificadas pelo juízo da execução.

Substituída a pena e também em razão do seu quantum, incabível o sursis penal (art. 77, caput e § 3º, do CP).

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para, com fulcro no art. 383 do CPP:

a) CONDENAR GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS, já qualificado, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, c/c art. 40, III e VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 199 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia multa, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana;

b) CONDENAR JOÁS MELKHIAS CARVALHO DA SILVA, já qualificado, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, c/c art. 40, III e VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 199 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia multa, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana;

c) ABSOLVER GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS e JOÁS MELKHIAS CARVALHO DA SILVA, já qualificados, da imputação da prática do delito do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Não houve alteração fática que justifique a imposição de prisão preventiva (arts. 387, § 1º, e 312 do CPP).

Custas pelos réus, nos termos do art. 804 do CPP, observada eventual gratuidade judiciária.

Oficie-se à autoridade policial, autorizando a incineração das drogas, se ainda não

ocorreu, devendo o fato ser certificado nos autos (art. 72 da LD).
Como a quantia apreendida está intrinsecamente vinculada à prática delitiva – produtos da mercancia da droga –, declaro seu perdimento em favor da União, devendo ser transferida para o FUNAD (art. 91, II, do CP).

Expeça-se certidão de honorários, caso os patronos dos réus tenham sido nomeados com base no convênio OAB/Defensoria.

Após o trânsito em julgado:

- a) oficie-se ao IIRGD, comunicando as condenações;
- b) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal;
- c) proceda-se ao recolhimento dos valores atribuídos a título de pena pecuniária, nos termos do art. 686 do CPP;
- d) expeçam-se guias de execução definitiva.
- e) cumpridas todas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

A inscrição em livros de registro do rol dos culpados foi abolida, conforme art. 372 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Sentença registrada eletronicamente.

Publique-se.

Intimem-se.

Barra Bonita, 09 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA